

법원(法源)으로서의 관행*

Pascale Deumier**

번역 박 수 곤***

논문요지

법원으로서의 ‘관행’은 다양하게 개념정의될 수 있으며, 그에 대한 연구 또한 법적용에 대한 문제의 총체일 수 있다. 즉, 관행에 대한 논의를 전개하기 위해서는 그 대상을 한정할 필요가 있다. 본 연구에서는 관행을 ‘행해지는 것’으로서 그리고 법원은 형식적 법원을 지칭한다. 이와 같이 개념 정의할 경우, 사실로서 비형식적인 것은 그 존재를 확인하기 어려우므로 도대체 이것들이 어떻게 법원이 될 수 있는지가 의문일 수 있다. 그런데 ‘관행’의 형성 과정에 대해 연구하다보면 그 효력을 보다 잘 이해할 수 있게 한다. 즉, 관행은 우선 사람들 사이의 관계에서의 특히 동일한 계약적 행태의 반복을 통하여 형성될 수 있다. 그리고는 그것들이 어떤 영역으로 확산되어 가는 것이다. 그리하여 관행이 그 행위자들과는 분리된 행위양태로 될 수 있을 것이다. 그리고는 당사자들 사이에서 묵시적으로 일종의 관례로서 적용될 수 있을 것이다. 이와 같이 재구성된 관행의 형성과정은 그렇다고 하여 관행을 관습이나 특정직능에서의 제안으로부터 명백하게 구분할 수 있게 하는 것은 아니다. 그러나 이와 같이 관행의 존재를 구별해 내기 어렵다고 하여 그러한 사정이 관행을 법원으로 다루는 것을 방해하지는 못한다. 즉, 관행의 창설적 효력은 계약, 법률 또는 관습으로부터 그 근거를 찾을 수 있을 것이다. 그러나 무엇보다도 관행의 파괴적 효력을 통하여 그 구속력을 설명할 수 있을 것이다. 환언하면, 관행은 일반적으로 행해지는 것이므로, 관행에서 배척당하는 것은 법률시스템의 중대한 장애요소가 될 위험이 있기 때문이다.

주제어 : 법원(法源), 객관적 법원, 형식적 법원, 관행, 거래관행, 규범적 효력, 임의규범, 실효

* 원고접수: 2013. 11. 11. 심사완료: 2013. 11. 22. 게재확정: 2013. 11. 22.

I. 들어가며

법원(法源 : source du droit)으로서의 ‘관행’(pratique)은 아주 기본적인 주제로서 누구

* 본 논문은 2012년 12월 14일 (사)한국법학원이 후원하고, 성균관대학교 법학전문대학원 및 프랑스 대륙법 재단에서 주최한 ‘2012년 韓佛 대륙법강좌 서울강연’에서 발표한 내용을 수정·보완한 글임을 밝힙니다.

** 프랑스 리옹 제3대학 교수

*** 경희대학교 법학전문대학원 부교수, 경희법학연구소 연구위원, 법학박사

도 그 중요성을 부인할 수는 없을 것이다. 즉, 법이 그 관행으로부터 항상 영양을 공급받고 있음을 부인할 수 있는 사람이 있겠는가? 법은 일종의 활동(또는 작용)으로서 본질적으로 관행에 향하고 있고 관행에 의해 인정받으며 또한 관행에 의해 구체화되거나 더 나아가 변형되기도 한다. 따라서 법에서 관행이 중요하다는 것이 일반적으로 인정되고 있음에도 불구하고 관행에 대한 이론적인 연구가 희소하다는 대조적인 현상은 상당히 인상적이다. 그러나 분명, 그와 같은 작업이 존재하지 않는 것은 아니다. 즉, 1983년의 앙리가 뼈땅 학술대회에서는 대주제를 ‘법의 형성에서의 ‘관행’의 역할’로 하였었다.¹⁾ 그리고 비교적 최근에는 ‘비즈니스법에서의 법원으로서의 관행’이라는 주제의 학술대회가 개최되고 그 발표문이 발간되기도 하였다.²⁾ 끝으로 법률체계의 구조적 요소로서의 관행의 역할은 ‘법학입문’(les introductions au droit)교재들에도 수록되어 있다.³⁾ 그리고 이 다양한 연구들을 검토하다보면 왜 그동안 법원으로서의 관행에 대한 분석이 적었는지에 대한 이유를 곧 바로 알 수 있게 된다. 즉, ‘법원’이라는 표현은 물론이거니와 ‘관행’이라는 표현 또한 너무나도 다양한 개념을 포섭하고 있어서 전체를 일관되게 개념화하는 것은 불가능하다는 것이다. 따라서 법원으로서의 관행에 대한 고찰을 수행하기 위해서는, 먼저 주제를 잘 확정할 필요가 있을 것이다. 그러므로 여기서 법원으로서의 관행의 절대적인 개념정의의 제시할 수 있다고 주장하는 것은 무용할 것이며, 다만 본 연구에서는 그와 같은 표현이 어떤 의미로 사용될 것인지를 구체화하는 것이 문제로 될 것이다.

1. ‘관행’의 개념

위에서 언급한 문헌들에서는 ‘관행’이라는 개념 하에서 동일한 표현을 사용하고 있지는 않은 것 같다. 그리고 이러한 사실은 법률용어사전에서 제시되는 개념정의로부터도 쉽게 확인된다. 즉, 일반적인 평가에 따르면 “이론과 대조하여, 법의 적용, 법의 실현, 법을 적용하는 활동의 총체, 법적용의 경험, 법실무가의 총체, 법을 적용하는 방식, 어느 직종에서 법을 적용하는 과정에서 형성된 관습, 재판소에서의 법적용, 특정분야에서의 행동양식, 반복적으로 행해지는 습관적인 행동양식으로서 거래관행이나 관습을 구체화 시킬 수 있는 것” 등이다. 그런데 이러한 다양한 관행의 개념이 누적되면, 이론 및 아직 적용되지 않아서 실행되고 있지 않은 법령을 제외한, 법 전체를 포섭할 수 있게 됨에 주의할 필요가

1) Journées suisses, Economica, 1985 Tome XXXIV, 1983.

2) dir. N. Molfessis, *Les Petites affiches*, N° spécial, 27 novembre 2003, n° 237.

3) F. Terré, *Introduction générale au droit*, Précis Dalloz, 9^e éd., 2012; P. Deumier, *Introduction générale au droit*, Manuel LGDJ, 2011.

있다. 그리고 관행에 대한 이런 다양한 표현들을 같은 움직임 내에서 분석하고자 한다면 이는 다시 이론과 관행의 차이를 연구하는 것으로 돌아가게 된다. 그런데 우리가 어떤 법원을 연구하고자 한다면, 그것을 따로 떼어 내어 다루어야 한다. 관행과 관련된 다양한 법원에 대한 단일한 분석들은 존재하지 않는다. 즉, 공증실무, 법원실무 그리고 법 실무자들의 관행은 법원으로서 동일한 특징을 나타내고 있지 않다. 따라서 어느 하나를 선택할 필요가 있다. 그러나 어떻게 선택할 것인가? 본 연구가 그 안내에 도움을 줄 것이다. 사실, 법원으로서의 관행을 연구함에 있어서, 가장 널리 활용되는 강의양식은 다른 근거들과 혼합되지 않고 관행에만 기초하는 표현이다. 즉, 법원실무 또는 행정실무, 국가 또는 우리의 위정자의 관행은 그들의 실질적인 영향력(힘)에 의지(근거)하지만, 이러한 현실은 그 행위자의 특별한 자격과 연결된 권위에 의해 배가된다. 그리고 이러한 것들에 또 다른 확산된 관행으로서 그 행위자가 알려지지 않고 또한 확인되지도 않는, 즉 법을 적용하는 자들 - 특히, 법관, 변호사, 조언자, 부동산중개인, 은행원 또는 보험자뿐만 아니라 법을 행하는 모든 자들 - 에 의한 법의 일상적 관행을 대조하는 것은 가능하다. 따라서 법의 수범자들에 의한 법적용 또한 관행에 해당한다. 그러나 여전히 그 개념은 광범위하다. 사실, 이러한 수범자들에 의한 각각의 법적용행위는 그 자체가 관행이다. 더 나아가, 프랑스나 유럽의 실정법(droit positif)은 ‘반경쟁적인’, ‘계획된(꾸며진)’, ‘남용적인’ 또는 ‘불성실한’ 거래관행⁴⁾과 같은 개별적 행위 또는 사실⁵⁾을 지칭하기 위한 용도로서 관행이라는 개념에 참고할 만한 것들로 넘친다. 여기서 또 한번, 법원(法源 : source du droit)의 관점에서 비로소 마지막으로 그 범위를 좁힐 수 있다. 즉, 법원으로 다루어지기 위해서는, 일반화될 수 있는 행위표본(modèle de comportement)으로서 특정한 상황에 적용함으로써 소진되지 않는 표본을 창출할 필요가 있다. 따라서 관행이 규범적 효력(effet normatif)을 발휘하기 위해서는, 그것이 개별적인 하나의 행위를 넘어 일정한 두께를 갖는 것이어야 한다. 이러한 관행은 그 반복과 일반화를 통하여 ‘행해지는 것’(ce qui se fait)일 것이다. 그리고 일정한 제한을 하더라도, 전체적으로는 여전히 그 수가 풍부하다. 비록 오늘날 프랑스법에서는 강행법규에 의해 규율됨으로써 실무적 혁신이 그다지 필요하지 않은 가족법⁶⁾ 또는 형사법⁷⁾ 분야에서 관행이 적절한 비율로 감소되기는

4) 유럽의회에서의 개념정의는 다음과 같다. “제품의 할인행사, 판매 또는 공급을 위하여 소비자들과의 직접적인 관계에서 이루어지는 모든 유형의 작위, 부작위, 행동, 광고와 마케팅을 포함한 전문가측으로부터의 상업적 교섭 또는 통신”(불공정한 상업적 거래관행에 관한 2005년 5월 11일의 유럽의회지침 제2005-29호, 제2조 d.).

5) 이와 같은 의미에서, B. Ricodeau, *La distinction des usages et des pratiques en droit économique français*, thèse, Orléans, 1983.

6) 그러나 민법 제372-2-11조에 따르면, 법원은 특히 “부모가 이전에 취했던 행동”을 고려하여 친권행사의 방법을 정할 수 있는 것으로 규정하고 있다.

7) 지속적인 지역적 전통이 있는 경우로서, 소싸움 및 닭싸움에 대한 형법 제521-1조의 가정용 애완동물에 대한

하였으나, 관행은 여전히 비즈니스법(droit des affaires)⁸⁾에서는 풍성한 법원으로 남아 있다. 그리고 금융시장법과 같은 특정 영역에서는⁹⁾ 관행에 의해 상정된 기법에 상당 부분 기초하기도 한다. 그런데 관행이 뿌리가 깊다거나 때로는 혁신적이라는 것은 그러한 관행에서 법원을 볼 수 있다는 것을 의미하는 것이 아닐까?

2. 법원의 개념

관행에 대한 이론적 연구가 많지 않지만, 그렇다고 하여 법원의 개념에 대해서도 마찬가지라고 말할 수는 없다. 그러나 (법원에 관한) 문헌의 상당부분은 (법원이) 너무도 다양한 개념을 가지고 있어서¹⁰⁾ 아무것도 제시할 수 없다는 개념에 대한 비판¹¹⁾에 할애되고 있다. 따라서 여기서 또 한번, 절대적인 가치를 가지는 법원의 개념을 제시하는 것을 시도할 것이 아니라, 본 연구에서는 법원이 어떠한 관점에서 이해될 것인지를 구체화하는 것이 중요하다. 그리고 위에서 살핀 바와 같이, 여기서의 법원은 특정한 상황을 뛰어넘는 행위표본, 규범을 창출하는 특징을 가지고 있다.¹²⁾ 따라서 일반적인 규범의 창출방법으로서의 법원은 상당히 광범위한 지배력을 갖는 개념이다. 그리고 이러한 개념 하에서는 규범의 내용상의 근거인 '객관적인(사실적인) 법원'(sources matérielles)과 그와 같은 내용이 법규범으로서의 형식을 갖게 되는 과정을 지칭하는 '형식적인 법원'(sources formelles)을 구별할 필요가 있다. 그리고 이러한 구별은, 비록 동일한 어려움이나 동일한 이해관계를 포섭하는 것은 아니라 하더라도, 관행과 관련한 문제에도 그대로 적용될 수 있다. 즉, 누구도 관행이 객관적인 근거라는 것을 부인할 수는 없을 것이다. 입법자나 법관들도 언제나 관행으로부터 발생한 법적 전형을 확립(인정)하였다.¹³⁾ 즉, 관행에서

학대를 이유로 한 불법행위를 예외로 한다. 동 규정으로 인하여 주기적으로 소송이 제기된다.

8) 국제상거래법과 계약적 관행 및 거래관행의 역할에 대해서는, J.-M. Jacquet, Philippe Delebecque et Sabine Corneloup, *Droit du commerce international*, Précis Dalloz, 2^e éd., 2010, n° 28 참조.; 상법분야에서의 다양한 거래관행과 관습에 대해서는, H. Kenfack et M. Pédamon, *Droit commercial*, Précis Dalloz, 3^e éd., 2011, n° 16 et s.; 계약법에서의 합의에 의한 개혁의 관행에 대해서는, F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, *Contrats civils et commerciaux*, Précis Dalloz, 5^e éd., 2001, n° 10 et 13.

9) “어떤 면에서는, 법원칙의 창설이 사유화(私有化) 되었다”고 평가되기도 한다. 이에 대해서는, A. Couret et alii., *Droit financier*, Précis Dalloz, 1^e éd., 2008, n° 28.

10) Ph. Jestaz, “Source délicieuse...”, *RTD civ.* 1993, 73.

11) P. Amselek, “Brèves réflexions sur la notion de ‘sources du droit’”, *APD*, Tome 27, 1982, p. 253.

12) ‘source de droit’와 ‘source du droit’의 구별에 대해서는, C. Thibierge, “Sources du droit, sources de droit : une cartographie”, in *Mélanges Ph. Jestaz*, Dalloz, 2006, p. 519 참조.

13) 예컨대, H. Roland et L. Boyer, *Adages du droit français*, n° 292 : 1880년 2월 27일의 법은 후견인에게 무채동산의 양도를 위해서는 허가를 얻도록 하였고, 1909년 3월 17일의 법은 영업자본의 양도를

인정되고 있는 혁신을 공식적으로 인정하는 것이 타당하다는 점에 대해 모두가 공감하면서, 이와 같이 (입법자나 법관들이) 수용하는 것에 대해 어떠한 논쟁이나 망설임도 제기되지 않는다. 따라서 진정으로 문제시되는 것은 오히려 형식적인 법원으로 될 수 있는 관행의 능력(capacité)을 명확하게 하는 것이다. 환언하면, 어떤 관행을, 기존의 전통적인 법원으로 포섭하지 않고, 새로운 규범으로서 창출할 것인지 그 범위를 확정하는 것이 문제로 된다는 것이다.

3. 관행과 법원(사실에서 법으로)

이와 같이 제한된 두 개념을 대조하는 것은 곧 바로 어려움을 드러내 보인다. 즉, 상황과 수요에 의하여 발생하고 존속하며, 다양한 형태로 그리고 어느 정도 그 모습을 확인할 수 있는(또한 관찰될 수 있는) 상태로 존재하는 관행이 어떻게 법원으로 성질결정될 수 있는지가 문제이다. 또한 범형성절차를 사전에 결정하는 것은 법이 담보하여야 할 법적 안정성에 비추어 필요불가결한 요소가 아니겠는가? 그리고 만약 법이 완전하게 확인할 수 있거나 그 연원을 구체화할 수 있는 것이 아니라 상황에 따라 자연적으로 발생할 수 있다고 한다면, 이러한 법적 안정성은 어떻게 되겠는가? 더 나아가, 보다 이론적인 측면에서도, 만약 관행이 사실이라면, 비록 프랑스법률가들에 의해 광범위하게 인정되고 있는 구별로서 사실의 세계와 법의 세계의 구별을 믿는다고 하더라도, 관행이 어떻게 법이 될 수 있다고 주장할 수 있겠는가? 결국, 관행은 법원의 반열로 올라가기에 충분한 자격을 갖는 것이 아니라, 법원에 복종하는 단순한 기능을 갖는 것에 불과한 것이 아니겠는가? 관행이 법원으로서 파악되기 위해서는, 법원이 법의 제정 절차나 법제정권력 및 법제정의 사에 의한 방법 이외의 방법에 의해서도 또한 발생할 수 있다는 것을 받아들이지 않을 수 없다. 실제로 우리는 사실이 고집스럽고 또한 사실은 가장 뿌리 깊은 이론에 복종할 줄 안다는 것을 알고 있다. 즉, 비록 관행이 전통적이고 형식적인 법원의 개념에 포함되지 않는다고 하더라도, 법원의 개념에는 관행의 존재에 적응하는 것이 포함될 수 있을 것이다. 그러나 법을 형성하는 이러한 사실의 능력을 어떻게 이해하고 범위를 확정하며 또한 설명할 수 있겠는가? 이와 관련하여서는 명백하고 공식적이며 일치하여 받아들여지는 설명은 존재하지 않으며, 각각의 질문 자체가 다양한 논쟁의 대상이 될 수 있다. 따라서 이와 관련한 문제들에 대해서 때로는 간략히 언급하거나 그 뉘앙스와 모호함을 모두 살피

공시하도록 하였으며, 1889년 7월 24일의 법은 친권의 상실에 대해 규정하였다. 상법에서는, 브뤼노가 자신의 저서에서("Sur la coutume en droit privé", *Droits*, n° 3, pp. 39 et s., 특히, p. 48 참조.), 1807년의 상법전은 본질적으로 관행 특히 어음과 관련한 관행을 합법화한 것으로 만족하였다고 평가한다.

지 못하는 점을 양해하기 바란다. 우선, 법원으로서의 관행에 인정될 수 있거나 인정될 수 없는 ‘효력’을 살피기에 앞서(II), 관행이 형성되는 과정을 더 잘 이해하도록 노력할 필요가 있을 것이다. 사실, 어떤 법원의 효력은 필수적으로 그 형성요건으로부터 유래한다(I).

II. 법원으로서의 관행의 형성과정

만약 관행이 ‘행해지는 것’이라고 한다면, 이를 엄격한 카테고리화 절차 내에 포섭시킬 수 있는 것으로 기대하는 것은 어렵다. 즉, 사실들은 너무도 복잡하고 다양해서 완벽한 단계로 그와 같이 정돈될 수 없다는 것이다. 더 나아가, 관행은 적어도 법률가들의 도구와 함께 법규가 준수되는 것에 저항적이며, 사회학자들이 오히려 그와 같은 연구를 수행함에 있어서 더 잘 무장되어 있다. 따라서 여기서는 현실을 묘사하기보다는, 학설상으로 또는 소송상 여기저기 분산된 요소를 모아서, 법원으로 포함되기에 충분한 비중으로 구성된 관행에 의해 차용된 일정한 방법(*certaines voies*)을 재구성하고자 한다. 이상과 같이 간략하게 언급한 과정을 더 기다릴 필요는 없을 것이다. 즉, 비록 관행의 확산과정을 대략적으로 재구성할 수는 있으나(A), 그렇다고 하여 그로부터 관행을 분명히 구별해 낼 수 있는 것은 아니다(B).

1. 관행의 확산

관행은 그 최초의 적용, 더 나아가 시대의 조류에 따라 동시의 여러 번의 적용에 의해 발생한다. 그리고 이러한 관행이 반드시 법테두리 밖에서는 충분히 개발되지 못한다는 것을 언급하는 것은 중요하다. 즉, 비록 우리의 법상황과 같이 복잡한 입법상황하에서 순수한 혁신에 해당한다고 할 수는 있을지라도, 오히려 법의 적용의 국면에서 충분히 개발된 관행을 의미하며, 이와 같이 충분히 개발된 관행은 그 시행의 순간에 있어서는 적용의 여지를 남긴다. 따라서 관행은 단순히 사실로부터 법으로의 단순한 상승움직임에 불과한 것은 아니며, 사실과 법 사이의 보다 복잡한 방식의 지속적인 게임이라고 할 것이다.¹⁴⁾ 계약분야에서는, 이러한 관행은 우선 개인 상호간의 관계의 단계에서 발생한다. 보다 큰

14) N. Molfessis, “Introduction”, in *Les pratiques juridiques, source du droit des affaires*, L.P.A., 27 novembre 2003, n° spécial 237, p. 4 참조; P. Puig, *R.T.D.civ.*, 2010. 513.

효율성을 담보하기 위하여 표준화에 의존하는 거래계의 요청들과 마찬가지로 관례에 대한 인간의 경향은¹⁵⁾ 이러한 동일한 행위를 반복하게 한다.

가. 인적 관계에 의한 관행

우선, 관행은 개인간의 관계에서 반복될 수 있다. 즉, 관행이 재생되는 경우로서, 예컨대 거래를 맺고 있는 계약관계에 있는 자들 사이에서 재판관할에 관한 규정을 두는 것과 같은 사례가 그러하다. 기업의 경우에도 마찬가지로, 예컨대 사용자는 계약이나 법령상의 규정과는 별도로, 크리스마스 보너스를 반복적으로 지급할 수 있다. 이 두 형태의 관행, 즉 거래관계(국제거래법분야에서는 당사자간의 관행으로 불리기도 함)¹⁶⁾와 기업 관행은 유사한 법적 효과를 발생시킨다.

그들은 우선 그와 같이 창설된 관행의 유지를 초래한다. 즉, 거래관계의 당사자 사이에서 침묵은 승낙의 가치를 지닌다. 이러한 예외는 이미 오래된 관례에 의해 확인되고 있으며, 구체적으로는 1867년의 판결¹⁷⁾을 들 수 있다. 예컨대, 계약상 아무런 개별 약정을 두지 않았다고 하더라도, 통상적인 계약적 특성에 부합하는 (목적물의) 인도 의무가 있다.¹⁸⁾ 마찬가지로 의무가 기업관행에서도 발생한다. 즉, 피용자는 법원에 사용자로 하여금 보너스를 지급하도록 청구할 수 있다.¹⁹⁾ 이 두 경우에서, 관행은 의사의 추정을 초래할 것이다. 사용자뿐만 아니라 계약상대방도²⁰⁾ 관행을 변경시키지 않겠다는 의사를 가진 것으로 추정된다. 달리 이야기하면, 과거에 취해진 행동은 현재의 의사를 추정하게 하는 지표로 된다. 따라서 관행은 규범적 효력을 가지는데, 왜냐하면 관행은 (당사자들이) 침묵의 경우 일종의 행위표본을 제공할 것이기 때문이다. 그런데 이러한 의무가 의사에 기초하기는 하나, 그렇다고 하여 이러한 동일한 의사가 새로운 의사에 의하여 반대 방향으로 종결된다는 것은 말도 안 된다. 그러나 이 순간에 관행은 또 다른 독창적인 효과를

15) J. Carbonnier, "La genèse de l'obligation dans l'apparition de la coutume", in *Flexible Droit*, L.G.D.J., 9ème éd., 1998, pp. 114 et s. ; 철학적으로는, F. Ravaisson, *De l'habitude*, Ed. FélixAlcan, 1933 참조.

16) 1980년 4월 11일의 비엔나협약 제9-1조, 1964년 7월 1일의 헤이그협약 제9조(당사자들은 자신들이 체결한 관행과 그들 사이에서 설정된 습관에 의해 연결되어 있다). 특히, 합의관할약정에 대해서는, 2000년 12월 22일의 브뤼셀규칙(Règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000) 제23조, 1. b. 참조.

17) Bordeaux, 3 juin 1867, *S.* 1868, 2, 183.

18) Cass. civ. 1ère, 30 mars 1999, *J.C.P.*, 1999, IV, 2001 ; *J.C.P.*, 1999 Ed. E, panor., 936 ; *R.J.D.A.*, 1999/6, n° 655 ; *G.P.*, 6 juillet 1999, panor., 24 ; *C.C.C.*, 1999, comm., n° 110, note L. Leveneur.

19) 예컨대, Cass. soc. 23 octobre 1991, *D.*, 1991, IR, 288.

20) 사용자의 의무부담의 성질 및 기업관행의 전문적 관행부재에 대해서는, E. Dockes, "L'engagement unilatéral de l'employeur", *Dr. Soc.*, 1994, pp. 227.

발생시킬 것이다. 즉, 어떤 행위가 반복적으로 행해진다는 것은 이러한 행위를 예견가능하게 한다는 점에서, 미리 유효기간을 준수하면서 그 의사를 종결시킬 것을 고지하여야 할 것이다. 만약 그와 같은 예방책이 없다면, 계약관계가 급작스럽게 해소되거나²¹⁾ 적법한 고지가 없었음을 이유로 하여 기업관행이 대항력을 갖게 될 것이다.²²⁾ 이에 대해서는 이상의 설명들에서도 살필 수 있을 것이며, 관행은 법이 고려하여야 하는 행위의 규범성 및 예견가능성에 대한 추정을 창설하는 '행해지는 것'으로 된다. 그런데 비록 이러한 설명이 기업관행에 있어서는 자주 제시되기도 하지만, 이 인간관계적 단계에서는 법원성을 발견하기가 힘들다.²³⁾ 사실, 그와 같이 창설된 행위표준은 그 행위자들에게 고유한 것으로 남으며, 그 행위자들은 언제든지 이를 종결시킬 수 있다. 법원의 논리로 들어가기 위해서는, (행위)표준이 그 행위자들의 범주를 넘을 것이 중요하며, 이는 관행의 일반화를 초래하게 된다. 이와 같은 범주초월은 관행의 확산의 정도에 상응하여 이루어질 것이다.

나. 확산의 원인 및 수단

그런데 어떤 이유로 인하여 몇몇 (개인간의) 관계에서 발생한 관행이 그 관계를 넘어서 존속하게 되는가? 몇 가지의 이유를 제시할 수 있을 것이다. 우선, 어떤 관행이 만약 유효하다고 한다면, 즉 관행이 공통적으로 인식되는 수요에 부합한다면 확산될 것이라고 평가할 수 있을 것이다. 다음으로, 이러한 완벽한 이미지와는 달리, 관행의 확산은 힘의 상관관계에 근거할 것이라고 평가할 수 있다. 즉, 자발적인 가입과는 무관하게, 관행이 더 힘이 큰 계약당사자에 의해 제시되고, 또한 계약일반조건 또는 표준약관에 일단 편입된 이상 당사자를 구속할 수 있게 된다는 것이다.²⁴⁾ 끝으로, 관행은 자연적인 경향에 근

21) 상법 제L.442-6조, I. 5.

22) 적법한 고지가 되기 위해서는, 사용자가 이해관계인에 대한 개별적 정보제공, 대표기관에 대한 정보제공을 담보하여야 하며, 이 또한 향후의 협상을 가능하게 하는 기간을 두고 이루어져야 한다. 예컨대, Cass. soc. 3 décembre 1996, *Bull. civ.*, V, n° 412.

23) C. Morel, "Le droit coutumier social dans l'entreprise", *Dr. soc.*, 1979, pp. 279 et s.; J. DEPREZ, "Pratique juridique et pratique sociale dans la genèse et le fonctionnement de la norme juridique", *R.R.J.*, 1997-3, pp. 799 et s., 특히, n° 7 : 동소에서는 기업관행을 법률이나 단체협약, 내부규칙과 같이 잘 알려진 다른 규범들에 추가되는 중요한 법원으로 평가하고 있다. 일방적 의무부담의 성질과의 비교에 대해서는, 전제, E. Dockes, 참조.

24) 이와 같은 우려에 대해서는, J.-M. Mousseron, "LEX MERCATORIA Bonne mauvaise idée ou mauvaise bonne idée?", in *Mélanges L. Boyer*, Presses de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse, 1996, p. 469. 특히, n° 26-27; B. Goldman, "Frontières du droit et 'lex mercatoria'", *A.P.D.*, Tome 9, 1964, pp. 177 et s., 특히, p. 188 : 국제상거래에서도 사실 '힘이 약한 자는 강한 자가 정한 규칙을 따른다'는 원칙에 따른다고 할 것이다. 국내 상법에 대해서는, Tanaka Kotaro, "Fonctions de la coutume en droit commercial", in *Mélanges F. Gény*, Tome 3, pp. 243 et s., 특히, p. 247 참조.

거할 수 있다. 즉, 이미 행한 것을 반복할 필요가 있는 관행 그리고 모든 사람이 행하는 것을 따를 필요가 있는 관행이 있다는 것이다. 그러나 어떤 계약당사자가 ‘행해지는 것’을 그와 같이 따를 수 있기 위해서는, 그가 그에 대해 알고 있어야 한다. 따라서 관행은 알려질 수 있는 것이어야 하며, 이를 위해서는 확산수단이 있어야 한다.²⁵⁾ 관행은 때로는 계약상대방에 의해 전달되기도 한다. 새로운 관행은 또한 일반법학잡지 또는 특정분야의 전문잡지를 통하여 공간의 대상이 될 수 있다. 관행은 학술대회, 심포지움 또는 단순히 커피자판기 앞에서의 만남을 통하여 소개될 수도 있다. 그러나 관행확산의 가장 경쟁력 있는 매체는 그것의 형식화라고 할 것이다. 최초의 형식화는 기업에서 계약일반조건이나 표준약관에의 삽입을 통하여 이루어질 수 있다. 그러나 형식화는 그것이 전문적인 조직의 행위로서 그 조직이 모든 영역에서 동일한 표준이 사용될 수 있도록 제한할 경우에 가장 빨리 확산될 수 있을 것이다. 그리고 그 결과물은 때로는 법전²⁶⁾으로 평가될 수 있는 단순한 모음집, 또는 오늘날 빈번하게 사용되는 것으로서 매매표준약관²⁷⁾ 또는 매매의 또 다른 일반계약조건의 형식을 취하게 될 것이다.²⁸⁾ 이러한 이유 그리고 이러한 수단에 의해서, 관행은 점진적으로 일반화될 것이다. 즉, 그와 같이 행해지고 반복되는 관행은 통상적인 행위로 나타날 수 있을 것이며, 또한 예견가능하므로 특정한 관계에서 뿐만 아니라 보다 일반적인 영역에서도 나타날 수 있을 것이다. 따라서 관행은 행위표본으로 사용될 준비가 되어 있다고 할 수 있다. 그리고 관행은 그 행위자들이 그 소멸을 좌우하지 못한다는 점에서 당사자의 의사를 넘어서고 있다. 즉, 비록 계약당사자들이 일반적으로 실행되고 있는 것과는 다른 방안을 예정하는 것이 가능하다고 할지라도, 이것이 관행을 종결짓는 것은 아니며 단지 하나의 예외를 구성할 뿐이라고 할 것이다. 관행은 이와 같이 반복과 일반화를 통하여 개별적인 의사를 능가하는 행위라고 할 수 있다. 그렇다고 하여 이러한 확산의 끝무렵에는 그와 같은 관행을 명확히 구분할 수 있을까?

25) 이러한 확산의 형태에 대해서는, Ph. Stoffel-Munck, 전제, “La diffusion des pratiques juridiques en droit des affaires”, in *Les pratiques juridiques, source du droit des affaires*.

26) 예컨대, 보석, 금은세공, 선물의 관행에 관한 기준 또는 정육점의 거래관행에 관한 기준.

27) 예컨대, 1961년 9월 19일의 판보에 게재된 공시분야에서의 표준약관 또는 ‘전국 예술가 및 창작광고예술가 협회의 관행에 관한 법전’(Code des usages du Syndicat national des artistes et maîtres artisans créateurs publicitaires).

28) P. Malinverni, *Les conditions générales de vente et les contrats-types des chambres syndicales*, L.G.D.J., Bibl. de droit privé, Tome 154, 1978. 저자는 이 책을 통하여 거래관행의 법형성적 기능을 강조하면서 거래관행을 덜 반영하는 표준약관보다 일반조건을 형성하는 가치가 있다고 한다.

2. 관행의 확인

법원은 적용될 표준을 제시하기 때문에, 그로부터 기대할 수 있는 최소한의 것은 법적 안정성의 형식이다. 즉, 그와 같이 창설된 규범을 확인할 수 있어야 한다는 것이다. 그런데 관행은 비공식적이고 자발적이며 실제적인 절차이기 때문에, 그와 같은 법적 안정성이 온전히 보장되어 있지 않다. 한편, 어떤 거래관행이 관행의 형식에 도달했는지의 여부를 판단하는 것이 때로는 어렵다. 다른 한편, 진정한 의미에서의 관행을 개인적인 제안과 구별하는 것 또한 때로는 어려울 수 있다.

가. 관행과 거래관행

(1) 효과의 차이

우리는, 개인적인 관계에서의 ‘관행’에서는, 명시적인 의사표시가 없는 영역에서는 무언가 반복되는 것이 관행의 적용으로 연결된다는 것을 살펴보았다. 일반화된 관행이 반복되는 것 또한 마찬가지로 유형의 효과를 발생시킬 것이다. 즉, 관행은 당사자가 침묵하는 경우에 적용될 것이다. 그러나 그와 같은 효과에 도달하기 위해서는 관행이 그 영역(secteur)에서 정상적이고 예견가능한 행위표본으로 될 수 있을 정도로 충분히 반복적인 것이어야 한다. 결국 두 가지 유형의 관행이 존재하게 된다. 즉, 그 하나는 반복되기는 하나 충분한 일관성(consistance)을 갖추지 못하여 당사자의 승낙이 없이는 적용될 수 없는 단계에 머물고 있는 관행이 있고, 다른 하나는 당사자의 승낙이 없더라도 적용될 수 있을 충분한 정도에 이른 관행, 즉 ‘거래관행’(usage)이 그것이다. 따라서 (양자의) 효과상의 차이는 당사자의 침묵의 여부와 관련이 있다. 즉, 당사자가 침묵하는 경우, 첫 번째의 관행은 적용의 여지가 없고, 거래관행이 적용될 것이다. 이러한 효과상의 차이는 그 형성과정에서의 차이에 기인한다.

(2) 형성과정의 차이

일정한 관행은 당사자가 침묵하는 경우에 적용되고 다른 것은 그렇지 않다면, 이는 그 일정한 것들만이 충분히 반복적으로 행해지는 상태에 이르렀기 때문이다. 그런데 이러한 설명은 참으로 납득하기가 쉽지 않다. 즉, 반복되는 관행은 도대체 언제 거래관행으로 될

만큼의 충분한 일관성을 갖게 되는 것일까? 이 질문에 대한 구체적인 답변은 존재하지 않는다. 즉, 사실이 법으로 전환되기 위해서는 어느 정도의 기간 동안 반복적으로 이루어져야 하는가를 정하고자 한 몇 몇의 시도들 중 어느 것도 성공을 거두지는 못하였다.²⁹⁾ 다만, 일정한 기준을 제시하는 것은 가능하다. 즉, 공간적으로나 시간적인 면에서의 일정한 두께의(épaisseur) 보편적 특성(다른 것들도 그러하다는 것) 및 일관성(항상 행해지고 있다는 것)이 그것이다.³⁰⁾ 보편성이 요구되는 이유는 그 정도로 어떤 그룹 내에서의 확산이 있어야 관행을 개별적인 의사로부터 분리시킬 수 있을 것이기 때문이다. 즉, 특정 그룹의 관행이 된다는 것은, 그 정도 되어야 더 이상 최초의 주장자의 의사에 의해 종결되지 않을 수 있기 때문이다. 일관성이 요구되는 이유는, 동일한 행위가 단절 없이 반복된다는 사실은 그것이 정착되었다거나 추인되었다는 것 이외에도 다른 기준의 관행이 포기되거나 최소화(minoration)되었음을 반증하기 때문이다. 이 점과 관련하여, 관행의 지속성은 그 역사성(ancienneté)보다 더 중요하다고 할 것이다. 즉, 적용사례가 드문 전래의 관행보다는 모든 사람들이 신속하게 따르는 관행이 더 가치가 있다는 것이다. 결국, 거래관행으로 전환되기 위하여, 이상과 같이 지속적이고 일반적으로 반복되는 현상이 어떤 관행을 마치 그것이 일정한 영역에서 '행해지는 것'인 것으로 승격시킬 것이다. 경쟁적인 관행이 유지되는 한, 그 분야에서 '거래관행'(usage)이 존재하는 것으로 평가하기는 힘들 것이다.³¹⁾ 따라서 이러한 것들 중 어떤 영역에서 실제로 행해지는 사실적 법칙으로 될 수 있는 능력(또는 자질)이 '거래관행'으로의 성질결정을 가능하게 하고 또한 그에 수반하는 효과를 얻게 할 것이다.

(3) 확인의 어려움

이상과 같은 막연한 설명을 극복할 것을 주장하는 것은 반드시 쉬운 일은 아니다. 어떤 반복적으로 행해지는 관행이 거래관행으로 전환되는 순간을 구체적으로 정할 수 있는 확

29) Merlin, *Répertoire de jurisprudence*, v° Usage : 저자는 관습법의 효력을 갖는 거래관행(usages secundum ou praeter legem)으로 간주되기 위해서는 10년 또는 20년의 기간이 필요하며, 법의 효력을 갖는 거래관행(usages contra legem)으로 간주되기 위해서는 40년의 기간이 필요하다고 한다. 다만, 법원(法院)의 재량권을 감안하여 이러한 입장을 상대화하기도 한다. 근자에 투우에 관한 '지속적인 지역관행'(tradition locale ininterrompue)이 되기 위해서는 20년이 요구된다고 한 것으로는, M. Marcilhacy pendant les débats devant le Conseil de la République : *J.O.*, C.R. 1951, p. 1071.

30) 관습에 대해서는, J. Carbonnier, *Droit civil - Introduction*, op. cit., n° 6.

31) 즉, 리용 항소법원은, 숙박업자가 무상으로 트럭운전자에게 식사를 제공하는 행위에 대해 이를, 비록 보편적인 관행이 아닌 예외적인 현상이라고 할 수 있으나, 숙박업자들의 상업적 관행이라고 분석하였다. Cass. soc. 23 février 1995, pourvoi n° 92-16.563, *Bull. civ.*, V, n° 73, p. 53 참조.

고한 기준은 존재하지도 않으며 존재할 수도 없다. 그와 같은 (순간의) 결정은 사례에 따라 행해질 수밖에 없으며, 법관이 이와 관련하여 때때로 그 평가에 있어서 놀라운 역할을 수행한다. 즉, 이러한 점에서, 일반화되지 않은 어떤 관행은 거래관행으로서 승인될 수 없다.³²⁾ 반면, 널리 퍼진 관행은 새로운 거래관행으로 인정됨에 있어서 그러하지 아니하다.³³⁾ 그러나 분쟁이 이 문제에 관여된 경우가 드물다는 것은 확인할 수 있다. 즉, 당사자는 거래관행의 적법성에 이의를 제기하거나 그들이 그와 같은 거래관행을 배제하였다고 주장하더라도, 그 존재에 의문을 품는 경우는 드물 것이라는 것이다. 그와 같은 경우, 비록 관행의 일관성의 정도는 그룹의 내부에서 확실히 인정된다고 하더라도, 법관은 (문제된) 그 영역의 전문기관의 확인서에 의지하게 될 것이다.³⁴⁾ 이와 관련하여, 이들 기관들이 거래관행을 성문화(또는 체계화, 편찬)하여 임시적으로 발간함으로써 일정한 해명을 제공할지도 모른다. 그리고 이는 그와 같은 발간의 형태를 취하는 것이 일반적으로는 거래관행에의 접근을 더 용이하게 한다고 설명되기도 한다. 그런데 이러한 발간은 어떤 영역의 관행을 확인하는데 도움을 주는 것이 아니라, 새로운 망설임을 초래하기도 한다.

나. 관행과 제안

관행의 작성은 종종 직능단체(organismes professionnels)³⁵⁾에 의해 이루어지기도 하는데, 이러한 단체들은 자발적으로 또는 공권력의 간섭에 의해 그러한 성문화(편찬) 작업을 기획한다.³⁶⁾ 이러한 것들 중 일정한 것은 ‘국제상업약관’(Incoterms)의 사례와

32) Cass. civ. 6 juin 1931, *S.* 1931, 1, 283에서는 ‘원산지명’(appellation d’origine contrôlée)과 관련하여, 원산지가 없는 경우, 어떤 제품에 이름을 부여하는 거래관행(usages)은 비록 그것이 반복적으로 이루어졌다고 하더라도 일인의 이해관계인 또는 그 동료들로부터 나오는 연속적인 -단순히 그들의 의향을 확인하는- 신고와 같은 개별적인 사실들로부터 도출되어서는 안 되며, 어느 정도의 일반적인 성격을 나타내는 것으로서 개별적으로뿐만 아니라 지역공동체로부터 승인되고 지켜지는 관행(pratique)을 구성하여야 한다.

33) C.C.I., 8873/1997, *J.D.I.*, 1998, 1017, obs. D. Hascher: 전형적인 합의에 의한 해결방안이 거래관행이 되기 위해서는, 차후의 어떤 요소와 협상할 필요 없이, (표준화된 형식으로서) 직접적으로 적용될 수 있는 통일성의 정도를 갖추어 거래실무에서 확립된 해결방안이어야 한다. 그리고 거래관행으로 고려하고자 하는 원칙들이 비록 계약상 명시하고 있지는 않았으나 문제된 영역의 일에 적용되었음이 증명되어야 한다. 이러한 형식의 적용에 있어서, 중재자들은 F.I.D.I.C.표준약관과 E.N.A.A.표준약관이 관행으로서의 가치가 없다고 평가한다.

34) Cass. com. 9 janvier 2001, pourvoi n° 97-22.668, *J.C.P.*, éd. E, 2001, 1337, note L. Leveneur ; *J.C.P.*, 2001, IV, 1384 ; *Contrats, conc., consom.*, 2001, comm. 70.

35) 이러한 현상에 대해서는, F. Leymarie, *Les usages commerciaux*, thèse, Bordeaux, 1970, n°s 267 et s. 참조.

36) 즉, 1952년의 내무부장관의 이행명령과 같이, 여러 유형의 데크레가 직능단체에게 권한을 부여하여 자신들의 직업윤리법전을 마련하게 하거나, 노동조합으로 하여금 자신들의 직업상의 관습과 거래관행의 존재를 확인하는 임무를 부여하기도 한다. 이에 대해서는, P. Malinverni, 전제서, 특히, n° 1.

같이 명성을 얻음과 함께 실무적으로도 상당한 중요성을 갖는 것들이 있다. 그런데 이러한 형식화는 관행을 왜곡시킬 우려가 있다. 이 위험은 전문직업인의 성문화(또는 체계화 : codification) 작업에만 고유한 것은 아니다. 즉, 예로부터 언제나 그리고 어디서나, 성문화는 관행의 현실을 두 단계로 왜곡할 우려가 있다.³⁷⁾ 우선, 성문화의 순간에 일정한 혁신이 도입될 수 있다.³⁸⁾ 다음으로 성문화 이후에 관행이 진화되거나 법문에 도입된 것에 더 이상 부합하지 않게 되는 경우가 있는데, 왜냐하면 관습은 흘러가는, 변하기 쉬운 것으로서 관행의 진화에 복종하는 한편 성문의 것은 고정되어 있기 때문이다.³⁹⁾ 그런데 직업적인 필요에 기원을 둔 성문화는, 사적인 연원의 규범과 관행으로부터 산출된 규범이 혼합될 수 있는 위험과 같은, 보충적인 위험을 갖고 있다. 그런데 특정 영역의 대표자가 참여하는 것이 관행을 담보(또는 증거)하지는 않는다. 즉, 이 대표자들이 새로운 표본을 제안할 때, 그들은 사적인 연원의 법원을 제시하지만, 그 산출물이 관행에서 실제로 (ipso facto) 받아들여질 것을 담보하지는 못한다. 그리고 이는 사적인 단체들에 의해 제안된 혁신안들이 사문화되어있는 사례들에서 잘 드러난다.⁴⁰⁾ 이러한 참여는 법원의 관점에서는 여전히 흥미로운데, 그 이유는 그와 같은 참여를 통하여 특정영역의 수요에 규범이 가장 잘 적응할 수 있기를 모색하는 한편 이를 통하여 수범자의 가장 큰 지지의 담보를 모색한다는 점에서 그러하다. 그러나 그렇다고 하여 관행도 그런 것은 아닌데, 그와 같이 성질 결정되기 위해 본질적인 것은 실행되어야 한다는 것이기 때문이다. 그리고 이 (실행되어야 한다는) 요건은 파기원 상사부가 일정한 혁신이 있다고 하여 상관습으로 인정할 수 없다고 설시함에 있어서, 이러한 권한이 “묵화의 수출업자 및 수입업자에 의해 일관성 있게 행사된 것이 아니라고” 밝히고 있는 것에서도 잘 나타난다.⁴¹⁾ 따라서 검증된 관행에 대한 혁신과 축성을 혼합한 직능관련 성문화는 서로 상이한 합리성들에서 끌어 온 규범을 뒤섞는데, 이는 특히 다음과 같은 유형의 혼합의 경우에 그러하다 : 즉, 경험에 의해 실험을 거치고 이미 인정된 표본을 제시하면서 관행을 유도하는 것; 이러한 원칙을 이미 과거에도 거래관행이라는 명목으로 존재하였음을 근거로 하여 소급적으로 적

37) J. Gilissen, (dir.), *La rédaction des coutumes dans le passé et dans le présent*, Université libre de Bruxelles, 1962.

38) 예컨대, CCI의 편찬과정에서의 이러한 섞임 현상에 대해서는, J. Stoufflet, « L'œuvre normative de la CCI dans le domaine bancaire », in *Mélanges B. Goldman*, Litec, 1982, p. 361.

39) Ph. Sueur, *Histoire du droit public français, XV-XVIII, siècle, 2/ Affirmation et crise de l'Etat sous l'Ancien Régime*, P.U.F., Thémis, 1989, p. 39.

40) 즉, 1978년에 CCI에 의해 도입된 약정보증을 위한 통일원칙은 실무상으로 큰 성공을 거두지 못하였다. J. Stoufflet은 이 원칙들이, 은행에서는 한 번의 신청에 의한 보증을 선호하였음으로 불구하고, 본질적으로 문서에 의한 보증을 예정하였을 뿐만 아니라 여전히 유동적으로 남아 있는 원칙 자체의 성격 때문에 관심을 끌지 못하였다고 한다.

41) Cass. com. 6 juillet 1966, *J.C.P.*, 1967, II, 15 088, obs. Ph. Kahn.

용시키려고 하는 것; 어떤 전략을 개발하면서 선제적인 거래관행이 존재하였다고 믿게 하는 것.⁴²⁾

이상과 같은 이유로 인하여 법원은 또 한 번 외관을 넘어, 그에 관한 성문화(또는 체계화) 이전에 거래관행이 존재하였는지 그리고 그 이후로도 그 거래관행들이 유지되고 있는지를 확인할 필요가 있다.⁴³⁾ 그러나 형식적인 권위의 무게는 느낄 수 있으며, 다만 우려할 만한 것은 법원이 거래관행에 부합하는 것으로 어느 정도 정당한 근거와 함께 추정됨에도 불구하고 그러한 추정에 의존하는 것을 선호하지는 않는다는 것이다.⁴⁴⁾

요컨대, 관행의 형성은 그것이 법원을 구성할 수 있는 그 능력에 대해 회의적일 수 있게 한다. 즉, 신뢰할 수 있는 방식으로 규범적 효력을 갖는 관행을 확정하는 것이 불가능하다는 것은 그와 같은 (관행의 능력의) 승인에는 부합하지 않는 것으로 보인다. 즉, 그와 같은 관행을 확인하는 것이 불가능함에도 불구하고, 어떻게 그러한 관행에 규범으로서의 자격을 인정할 수 있겠는가? 관행이 그것을 승인하려는 의사 또는 그 효과를 인정하고자 의사 중 어느 하나에 대한 선택에 근거를 두는 것이 아니라면, 관행의 효력(force)은 완전히 그 존재사실에 근거하며, 또한 이러한 사실은 부인될 수 없다.

III. 법원으로서의 관행의 효력

관행의 효력(force)은 종종 눈의 띠지 않고 지나간다. 즉, 관행은 종종 아무 것도 창설하지 않거나 아무 것도 부인하지 않는다. 관행은 이미 법정의 또는 판례에 의한 어떤 법원에 의하여 추천되는 행위를 쫓아간다. 따라서 관행은 다른 유형의 법원에 의해 제시된 규

42) M. Favero, "La standardisation contractuelle, enjeu de pouvoir entre les parties et de compétition entre systèmes juridiques", *R.T.D.com.*, 2003, 429.

43) Paris, 30 juin 1964, *J.C.P.*, 1965, II, 14 058 : 동 판결에서는 어느 금속업 직능단체의 매매계약일반 조건들이 그것이 거래관행으로서의 효력을 가지는 경우 또는 합의에 의해 선택된 경우에만 적용될 수 있다는 것을 확인한 후, 이와 같은 조건들이 적용되지 않는 匠人(artisan)과 이와 같은 조건들의 존재를 알면서 매일 이를 활용하는 '전문적인 계열회사'(société professionnelle de la branche)를 구별하고 있다.

44) Lyon 8 février 1961, *Gaz. Pal.*, 1961, 1, 261 : 앤 농림부(Chambre d'agriculture de l'Ain)는 경작지에 대한 식재거리에 관한 거래관행이 6미터라고 하였다. 그러나 원고는 규정내용의 모호함을 이유로 그 거리가 3미터라고 주장하였다. 항소법원은 청구를 기각하면서, 농림부가 정확한 형식에 대해 모호함을 보인 것은 그 시대의 상황에 따른 것으로서, 식재에 관한 지역관행에 대한 농림부의 법전화에 인정되는 적법성의 추정은 반대의 증거 및 더 나아가 몇몇 진지한 추정에 의해서도 반복될 수 없다. 이와 관련하여 항소심이 공시분야에서의 일반적인 관행을 규정한 표준약관을 적용한 것을 인정한 파기원의 판결로는, *Cass. com.*, 5 novembre 1968, *J.C.P.*, 1969, II, 15 938, obs. J.-M. Leloup.

법의 실행(effectivité)으로 되며, 그 다른 법원이 관행의 소권을 흡수할 것이다. 관행은 다른 법원에 의해 이미 예정된 행위표본으로부터 멀어지면서 그것이 혁신할 때 보다 더 쉽게 파악된다. 그러나 이러한 관행의 창조적 효력을 부인하기란 쉬운 일이 아니다. 즉, 기껏해야 이러한 효력의 강도를 상대화하거나 그 근거의 박약성을 지적할 수 있을 뿐이다. 사실이 법을 창설할 수 있는 능력의 정당성에 관해서는 오래전부터 논쟁이 제기되어 왔으며 여전히 해결책이 제시되고 있지는 않다(A). 그러나 관행의 효력은 그와 같은 망설임을 허용하기에는 상당히 강하며, 이러한 효력은 관행이 다른 유형의 법원과 충돌이 있을 때 드러난다(B).

1. 관행의 창설적 효력

관행에 의해 확립된 어떤 행위표본이 위반을 이유로 법관에 의해 제재를 받을 수 있을까? 사실, 관행의 사실상의 효력 및 혁신의 유용성이 무엇이건 간에, 법관에 의하여 제재를 받을 수 있는 이러한 성격이 없다면 법원으로서의 진정한 가치를 인정하기가 쉽지 않을 것이다. 관행은 다양한 형태로 나타난다. 따라서 그 효력 또한 다양한 메카니즘에 근거할 수 있다.

가. 계약의 효력

관행은 승낙된 것으로서 법률효과를 발생할 수 있다. 즉, 표준약관, 일반계약조건 그리고 거래관행이 그러한데 특히, 직업적인 영역 밖에서 이들의 적용을 주장하는 경우에 그러하다.⁴⁵⁾ 따라서 권한(또는 허락 : autorité)이 직접 계약의 효력에 근거하는 경우에는, 관행이 법원의 관점에서 어떠한 의미 있는 효력을 갖지 못하는 것으로 평가할 수 있다. 그러나 관행이 어떤 규범적 표본을 제안하는 것을 허용하고, 그 규범적 표본은 상황에 따른 개별적 협상을 면하게 하며, 또한 임의법규 보다 특정분야의 요구에 더 부합하는 -관행이 직업적 영역에서 제안된 것이기에- 것이라는 것을 확인할 수 있다. 즉, 계약분야에 있어서, 의사와 규범 사이의 '분절'(articulation)은 보충적 의미(dimension)를 갖는다. 즉, 점점 더 규범은 표준원칙으로 다루어지며, 그 적용은 'opt in'(사전동의) 또는

45) 관행은 전문직업인의 영역 밖에서는 명시적인 승인이 있는 경우에만 적용될 수 있다. : Cass. com. 8 octobre 1956, *Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale*, Sirey, Tome 1, n° 3, obs. M. Pédamon ; Cass. com. 4 mai 1999, *D. Aff.*, 1999, 930, obs. X.D. ; *Defrénois*, 1999, art. 37041, n° 73, obs. Ph. Delebecque ; *J.C.P.*, éd. E, 2000, 895, note Ph. Neau-Leduc.

‘opt out’(사후동의)의 형식으로 명시적인 의사표시에 의존한다.⁴⁶⁾ 의사(volonté)는 (그 권위를 존중하는 범위 내에서) 법령을 적용하는 효과를 가지는 (자기결정권의 존중의 범위 내에서) 선택을 행한다. 선택권(option)은 혼합하거나 종속시키지 않고, 표본의 적용범위 내에서 계약을 포섭시키거나 배제하는 것을 선택한다. 선택권은 법령의 적용가능성에 관한 것이며, 그 구속력이나 그 권한의 근거에 관한 것이 아니다.⁴⁷⁾ 비록 모든 규범적 표본이 그 기원을 사적인 것에 두건 아니면 unidroit와 같은 학술적인 것에 두건 ‘opt in’ 방식으로 선택될 수 있으나, 표본은 ‘opt out’의 메카니즘 내에서 그 적용의 근거를 찾을 수 있는 것이어야 한다. 그런데 관행 중에는 거래관행만이 ‘opt out’의 메카니즘에 속한다. 그와 같이 이해할 경우, 어떤 관행이 거래관행으로 전환되는 것은 사실을 법으로 변경하는 마법과 같은 힘을 갖는 것이 아니라, ‘opt in’ 방식(표준약관의 적용)을 ‘opt out’ 방식(관행)으로 바꾸는 흥미롭고도 설명되지 않는 힘을 갖는 것과 비견된다. 따라서 거래관행의 효력의 근거를 찾을 필요가 있다.

나. 법의 효력

법은 매우 종종 관행상의 태도를 편입하거나 승인한다. 비록 유명한 몇몇 법들에서 알려진 것이기는 하나, 아직도 명령의 분야에서는 자주 채용되는 방법으로서 특히 보험이나 운송의 영역에서는 데크레로 승인되기 전에 그 직업종사자와의 협의를 통하여 작성된 표준약관이 광범위하게 근거로 작용한다. 위에서도 언급한 바와 같이, 거래관행은 본질적으로 ‘사실적인 연원’(une source matérielle)의 역할을 하며, 그것이 첫 번째의 구상이기도 하다. 그리고 거래관행이 확립되지 않은 영역에서는, 법령의 위임에 의해서도 또한 거래관행이 적용될 수 있다.⁴⁸⁾ 예컨대, 법이 해고의 경우에 있어서의 해지통고(préavis)를 예정하고 있기는 하나, 그 기간은 ‘그 지역이나 업종에서 행해지는 거래관행’⁴⁹⁾에 따를 것이다. 여기서 특정 영역의 수요에 더 잘 부합하는 것으로 추정되는 규범

46) S. Lemaire, “Le choix de la loi du contrat en droit interne”, *R.R.J.*, 2001-3, 1431.

47) P. Deumier, “La force normative optionnelle”, in *La force normative. Naissance d’un concept*, C. Thibierge (dir.), L.G.D.J., 2009.

48) 그리고 이는 민법 제1135조를 통해서도 알 수 있다. 그러나 새로운 법이 제정될 때마다 주기적으로 그에 따르게 된다. 그와 같은 예로는, 전국변호사협회의 권한확정을 위하여 일정한 지역의 전문법조인의 지위를 개정하는 2004년 2월 11일의 법 제2004-130호; 기업에의 금융중단을 위한 사전통고기간의 확정을 위한 은행의 관행과 관련한 2003년 8월 1일의 법 제2003-721호; 관습을 수집할 권한을 농림부에 부여하는 전원법전 제L.511-3조에 추가된 기계적 위험의 예방과 손해배상에 관한 2003년 7월 30일의 법 제2003-699호(이와 같은 관습 및 지역적 관행의 수집은 제L.114-1조에서 규정한 침식지역 내에서 특히 규칙적으로 행해진다); 형성된 상사관계의 갑작스러운 중단에 관한 사전통고를 위한 새로운 경제규칙에 관한 2001년 5월 15일의 법 제2001-420호.

의 논리를 다시 찾게 된다. 그리고 이와 같이 적용하는 것은 법에서 근거를 찾을 수 있기 때문에, 구체적으로 근거를 찾을 필요는 없어 보인다. 그러나 법이 거래관행에 위임을 하는 경우, 구체적으로 어디에 위임을 하는지를 살필 필요가 있다. 즉, 국제중재의 분야에서 특히 이 문제가 제기된다. 중재인은 모든 경우에 있어서 국제적인 상거래관행을 고려할 의무가 있다.⁵⁰⁾ 그런데 중재인이 그와 같은 근거에 입각하여 판단을 내리는 경우, 여전히 법에 근거할 것인가 아니면 형평에 근거할 것인가? 이와 관련하여, 파기원이 드물게 판단을 내린 경우가 있는데, 동 판결에서는 거래관행의 법원칙으로서의 성질(qualité)을 명백히 확인하면서 거래관행의 규범적 효력을 인정하였다.⁵¹⁾ 그러나 이러한 성질은 이 거래관행이 법의 침묵으로 인하여 적용될 때에는 종종 논쟁의 대상이 된다.

다. 관습의 효력

거래관행이 당사자의 승낙 없이도 적용될 수 있는 성질의 근거를 해명함에 있어서는 두 가지의 견해가 대립되고 있다. 우선, 거래관행은 당사자의 묵시적 의사에 근거하여 적용된다는 것이다.⁵²⁾ 즉, 동일한 영역에 속하는 당사자들로서는 그와 같은 거래관행을 알고 있는 것으로 추정된다는 것이다. 따라서 당사자가 거래관행을 배제하지 않았다면, 그러한 거래관행의 적용을 승낙하였을 것이라는 것이다. 다음으로, 거래관행은 그 고유한 효력 즉 보충규범(임의규범 : norme supplétive)으로서의 효력에 의하여 적용된다.⁵³⁾ 즉, 당사자들은 거래관행에 의해 연관된 직업군에 속하기 때문에, 그 적용범위에 포섭된다는 것이다. 그리고 보충규범은 당사자에 의해 배제되지 않는 한 적용될 수 있다. 보다 구체적으로는, 두 가지의 입장이 하나의 동일한 해결책으로 도달하는 현상에 주목할 필요가 있다. 즉, 거래관행은 명시적으로 배제되지 않는 한 적용된다. 또한 계약적인 근거

49) 또는 호의원칙에 따른 단체협약이나 근로계약, 이에 대해서는 노동법전 제L.1234-1조 참조.

50) 민사소송법 제1511조.

51) Cass. 1^{re} civ., 22 octobre 1991, Valenciana, *J.D.I.*, 1992, p. 177, note B. Goldman ; *Rev. crit. DIP.*, 1992, p. 113, note B. Oppetit ; *R.T.D.com.*, 1992, p. 171, obs. E. Loquin.

52) 학설상으로는 특히, F. Gény, *Méthodes d'interprétation et sources du droit privé positif*, L.G.D.J., 2e éd., 1954, n° 1301 ; A. Kassis, *Théorie générale des usages du commerce*, 1984, L.G.D.J. ; 판례상으로는, Cass. soc., 13 octobre 1966, *Bull. civ.*, IV, n° 779, ; Cass. com., 8 octobre 1956, *Bull. civ.*, III, n° 225 ; Cass. com., 9 janvier 2001, *J.C.P.*, éd. E, 2001, 1337, note L. Leveneur.

53) P. Deumier, *Le droit spontané*, Economica, 2002 및 전술한 참고문헌 참조. ; 판례에 대해서는, Cass. soc. 3 juillet 1952, *Bull. civ.* IV, n° 569 ; Cass. Com. 3 mai 1966, *Bull. civ.*, III, n° 227 ; Cass. 1^{re} civ., 4 juillet 1995, *Resp. civ. et assur.*, 1995, comm., 329 ; 국제상법분야에 대해서는, Valenciana, 전게논문 참조. ; 법률(loi) 이외에 거래관행에 대해 규정하고 있는 법규정으로는, 민법 제1135조, 전원법 제L.511-4조, 제L.651-6조 ; 해양노동법 제17조 및 제50조.

나 법령의 위임이 없는 영역에서 거래관행이 적용될 수 있는 경우들은 상대적으로 드물다는 점을 주목할 필요가 있다. 그런데 프랑스의 실정법은 전혀 도움이 되지 않는데, 왜냐하면 두 가지의 발상 각각으로부터 근거(soutien)를 찾을 수 있기 때문이다.⁵⁴⁾ 각각이 법원을 가진다는 다소 유연한 발상에 의하지 않고서는 논쟁을 해결하는 것이 불가능하다. 그런데 여기서 우리가 취하고자 하는 입장은 관습의 효력과 마찬가지로 고유한 효력에 근거한 진정한 규범으로서의 거래관행을 지지하는 입장이다. 그러나 전통적인 설명에 따를 경우 관습과 거래관행의 구별에 있어서는 다소의 망설임이 있을 수 있다. 프랑스에서는 Géný⁵⁵⁾에 의해 이어져 온 고전적인 발상에 따를 경우, 두 가지 모두 분명 관행에 해당하는데, 그 이유는 종래부터 지속적이고 보편적으로 반복되고 있기 때문이다. 반면, 이러한 고전적인 발상에 의하더라도, 관습만이 법원이라고 할 것인데, 그 이유는 관습만이 위와 같은 사실적인 요소에 덧붙여 심리적인 요소, 즉 관행은 강제적이라는(obligatoire) 느낌을 추가적으로 요구하고 있기 때문이다. 그런데 이러한 설명은 오늘날에 와서는 점점 더 의문시되고 있는데, 그 이유는 다음과 같다.⁵⁶⁾ 우선, 이러한 설명은 실정법의 태도에 부합하지 않는다. 즉, 법원으로서 가장 공식적으로 인정되고 있는 관행은 '거래관행'(usage)으로서, 특히 국제상거래관행을 들 수 있는데, 이는 법원칙으로 인정되고 있으며 국제중재에 있어서는 반드시 이를 참작하여야 하기 때문이다. 더 나아가, 프랑스 판례는 위와 같은 설명을 단 한 번도 확인한 적이 없다. 즉, 어디에도 관습과 거래관행의 구별흔적을 찾을 수 없다(법관들은 보편적으로 거래관행에 대해 이야기한다). 그리고 최소한의 심리적인 요소를 발견하고자 한 흔적도 존재하지 않는다. 다음으로, 양자를 구별하기 위하여 사용되는 기준이라고 할 수 있는 강제적인 성격에 대한 확신이라는 기준마저도 비판의 대상이 되고 있다. 이와 같은 기준은 법이 착오에 의해서도 발생할 수 있다는 논리에 입각하고 있다. 그러나 도대체 무슨 이유로 관행을 좇게 되었는지 그 심리를 파악한다는 것은 어려운 일이므로, 그와 같은 기준은 절대로 관찰되거나 확인될 수 없을 것이다. 요컨대, 그와 같은 인식(sentiment)은 형성요건 또는 구별기준이라기보다는 일종의 '설명'의 단서(clé d'explication)에 불과한 것이라고 할 것이다. 즉, 어떤 관행이 행해지고 있었기 때문에, 그것이 비록 의무는 아닐지라도 때로는 정상적이라

54) 합의에 의한 거래관행의 유동성에 관해서는, Cass. soc. 13 octobre 1966, *Bull. civ.* IV, n° 779, ; CA Pau, 29 février 1960, *Gaz. Pal.*, 1960, 1, 317 ; Cass. com. 8 octobre 1956, *Bull. civ.* III, n° 225 ; Cass. com., 9 janvier 2001, *J.C.P.*, éd. E, 2001, 1337, note L. Leveneur ; 국제적인 거래관행에 관한 판결 이외에 규범적 거래관행에 대해서는, Cass. soc., 3 juillet 1952, *Bull. civ.* IV, n° 569 ; Cass. Com. 3 mai 1966, *Bull. civ.* III, n° 227 ; Cass. 1^{er} civ., 4 juillet 1995, *Resp. civ. et assur.*, 1995, comm. n° 329.

55) F. Géný, précité.

56) 보다 상세한 내용에 대해서는, P. Deumier, précitée.

는 어떤 느낌을 불러일으키고, 이러한 것이 그 규범적 효력을 설명하게 된다는 것이다. 끝으로, 이상과 같은 다양한 이해의 방향으로 인하여, 학설상으로는 점점 더 양자의 구별을 포기한다거나⁵⁷⁾ 또는 단순한 일반론상의 차이에만 집착하는데 그치고 있다.⁵⁸⁾ 즉, 관습은 일반적인 관행일수 있으나, 거래관행은 일정한 지역이나 영역(secteur)에 국한된 관행이라는 것이다.

라. 효율성의 근거

거래관행의 효력을 관습에서 찾는 것은 중국적으로는 논의의 방향을 선회하는 것이 된다. 즉, 법원으로서의 관습의 권위 또한 논의의 대상이 되었으며, 다수의 견해는 그 효력을 법에 의한 위임으로 축소하고자 한다. 그리고 그러한 위임은 종종 관습에 반하기도 하는데, 특히 프랑스법에서는 그것이 승인되고 적용되는데 있어서 전혀 제지되지 않았다. 법일반론의 관점에서, 관습을 분석하고자 한 수많은 시도들 중, Roberto Ago는 법률가들이 관습을 이해함에 있어서, 그리고 더 나아가 자발적인 법으로서 관행에 의해 발생한 법을 이해함에 있어서 직면하는 어려움을 설명하고 있다.⁵⁹⁾ 사실, 다양한 법이론의 조류는 항상 중국적으로는 법의 효력을 어떤 의사로 귀결시킨다 - 비록 그것이 무엇이건 간에 (신, 고권의사, 국민의 집단적 의사) -. 그리고 이러한 경향은 우리가 다루고 있는 주제에서도 그대로 나타난다. 즉, 거래관행의 적용을 설명하기 위하여 당사자의 묵시적 의사를 찾고자 한다면, 관습의 효력을 설명하기 위하여 입법자의 가정적 의사를 찾고자 한다는 것이다. Roberto Ago는 이러한 방식으로 자발적으로 발생하는 법을 포섭할 수 없다고 설명하는데, 왜냐하면 자생하는 법은 어떤 규범을 정하고자 하는 의사의 과실(fruit)이 아니기 때문이라고 한다. 즉, 관행에서 발생하는 규범은 그 자체로서 의욕되었던 것이 아니라, 사실로부터 발생된 것이며, 그 존재 사실에 의해 강제되고 효력이 발생한다. 지속적이고 보편적인 반복에 의해 확립되는 이와 같은 존재사실은 그 효율성(effectivité)을 담보하게 된다. 비록 이러한 효율성이 오랫동안 법률가로 하여금 그것을 극복함에 있어서 주저하게 만들기는 하였으나, 법분야에서의 그 중요성은 점점 더 크게

57) F. Osman, *Les principes généraux de la 'lex mercatoria'*, 1992, L.G.D.J., p. 424 et s. ; Ph. Fouchard, *L'Etat face aux usages du commerce international*, TCFDIP, 1973, 75.

58) 같은 취지로는, G. Cornu, *Droit civil, Introduction, les personnes, les biens*, 10^e éd., 2001, Montchrestien, n^o 420 et s. ; Ph. Le Tourneau, "Quelques aspects de l'évolution des contrats", *Mélanges P. Raynaud*, 1985, Dalloz-Sirey, p. 349, n^o 57.

59) "Droit positif et droit international", *A.F.D.I.*, 1957, p. 14 ; "Science juridique et droit international", *R.C.A.D.I.*, 1956-II, Tome 90, p. 851.

인정되고 있다. 법은 더 이상, 완전히 강제적이고 법률가에 의해 제재할 수는 있으나 사실관계에서 전혀 반향이 없는 법원칙에 그치지 않는다. 요즘 들어 연구의 대상으로 되는 것은 그것이 사실관계에서도 지켜지는 원칙이며, 따라서 이러한 이유들로 인하여 제재수단 이외의 또 다른 수단일 수 있다는 것이다. 그러므로 관행에 더 큰 가치가 부여되며 관행이 더 주목의 대상이 되고 있는 것이다. 법의 근거를 이와 같이 확대하는 방식은 특히 François Ost와 Michel van de Kerchove에 의해 이론화되었는데,⁶⁰⁾ 이들은 법에서 ‘합법성’(légalité), ‘정당성’(légitimité), ‘효율성’(effectivité)이라는 세 가지의 효력(validité)에 주목한다. 그런데 관행이, 비록 위에서 언급한 바와 같이 때로는 법적 근거를 가질 수는 있으나, 원칙적으로 효율성에 근거할 것이라는 점을 확인하는 것은 결코 어렵지 않다. 그러나 가장 큰 어려움은 이 세 가지 근거를 충족시키는 문제는 아니라고 할 것이다. 즉, 동시에 적법하고, 정당하며, 효율성 있는 규범은 승인의 문제만을 남긴다. 진정한 어려움은 이 여러 가지의 근거들이 서로 결합되는 것이 아니라 대립하고 있는 경우에 발생한다. 사실, 관행이 효율성에 근거한 법원이라면, 이 관행이 적법성에 근거한 법원과 대립되는 경우에 어떻게 처리하여야 할 것인가? 분쟁의 해결책은 간단해 보일 수 있다. 그러나 사실은 결코 그렇지 않으며, 관행의 창조적인 작용(action) 내에서 그 파괴적인 작용(action)은 그 효력의 중요성에 대하여 인식할 수 있게 한다.

2. 관행의 파괴적 효력

관행의 효력은 다른 법원과의 관계에 있어서 보다 부정적인 측면에서 밝혀질 수 있다. 이러한 새로운 입장(configuration)에서는, 관행이 일반화된 거래관행 또는 실무인지, 아니면 진정한 법원칙 또는 단순한 묵시적 합의인지를 밝히는 것이 중요하다. 즉, 여기서 고려되는 것은 그 본질 자체, 즉 그것이 존재한다는 것이다. 그런데 이와 같은 실재(existence)는 그 위력을 드러내게 될 것인데, 왜냐하면 그것이 다른 법원을 파괴할 수도 있고 또한 역으로 그것을 삭제하고자 하는 다른 법원의 주의를 끌게 할 수도 있기 때문이다.

가. 관행과 다른 법원의 효력의 약화

관행은 다른 법원을 파괴하고 법률이라고 하는 우리 체제에서 가장 상징적인 법률로 진화할 수 있는가?⁶¹⁾ 이러한 질문은 이미 어떤 원칙의 실효(désuétude) 또는 시대불부

60) F. Ost et M. van de Kerchove, *De la pyramide au réseau ?*, FUSL, 2002.

합(obsolescence)이라는 형식으로 다루어져 왔다. 그리고 이에 대한 답변 또한 어떤 법칙이 더 이상 실행되지 않거나(désuétude : 실효) 더 이상 관행에 부합하지 않더라도(obsolescence : 낡음), 그 법원칙은 그것이 암묵적으로라도 폐지되지 않는 한 효력을 가지고 있다는 것이다. 이러한 공식적인 입장은 수차에 걸쳐 법원에 의해 확인되었다. 관련 사례로서 오래되기는 하였으나 이에 대해 명확한 입장을 밝히는 것은 다음과 같다. 마르세이유에 적용되는 1958년 12월 10일의 지방조례에서는 자동차나 짐수레의 운전자에게 자동차의 바퀴가 인도를 침범하지 못하게 규정하고 있었다. 그런데 몇 년 후, 전차회사에서는 동 규정의 적용을 받지 않겠다고 하였다. 사실, 몇몇 도로는 그 폭이 너무 좁아서 자동차가 인도를 침범하지 않고는 전차나 자동차가 교차할 수 없는 상황이기도 하였다. 따라서 운전자들이 이와 같은 인프라의 변경에 대응하여 새로운 운전습관의 허용을 요청하였다. 그리고 이러한 새로운 행동양식(pratique)을 단순한 관행, 거래관행 또는 관습으로 성질결정하고자 하는 것은 대단히 모험적이라고 할 것이다. 그런데 사고가 발생하였다. 즉, 한 어린 소년이 인도에서 미끄러졌고 짐수레가 지나갈 때 넘어지는 바람에 다리를 다치게 되었다. 짐수레 운전자에 대해 소송이 제기되었고, 그 근거는 1858년 조례의 위반이었다. Aix 항소법원은 더 이상 상황에 부합하지 않는 조례의 적용이 곤란하다는 관행의 반응을 인식하여 그와 같은 사고가 운명적인 것이라고 하여 기각하였다. 그러나 파기원은 “법령은 실효에 의해 폐지되지 않는다”⁶²⁾고 하여 엄격한 태도를 견지하였다. 이러한 사례는 두 가지를 시사한다. 우선, 제대로 된 관행이라 하더라도 반드시 기성의 원칙에 우선하지는 않는다는 것이다. 그런데 이러한 입장은 불합리한 결과를 초래할 수 있다. 즉, 학설이 이 문제에 대해 당혹스러워하더라도 그것은 전혀 놀랄만한 일은 아닐 것이다. 가장 자주 접하게 되는 입장은 Jean Cruet가 완벽하게 요약한 다음과 같은 입장이다. “실효(désuétude)는 법의 사망이지만 그렇게 말하지 않는 것이 바람직하다”⁶³⁾는 것이다. 그러나 기성의 원칙과 반대되는 관행 사이의 불균형이 얼마나 쉽게 해결하기 어려운지에 대해서는 또 다른 두 상징적인 견해를 통하여 보다 명확하게 묘사될 수 있다. 그 하나는 François Génys의 견해이다. 프랑스에서 그는 관습과 그 효력을 재

61) 이 문제는 판례를 통하여 다른 개념으로 논의의 대상이 될 수 있다. 즉, 어떠한 해석이 견고한 판례가 되기 위해서는 그와 같이 수용되어야 할 것이다. 따라서 결국 어떤 판례가 관행에서 다시 채택될 수는 없는지가 의문일 수 있다.

62) Cass. crim., 4 Janvier 1917, *S.*, 1921, I, p. 331.

63) J. Cruet, *La vie du droit ou l'impuissance des lois*, 1908, Flammarion. 포탈리스의 서정시를 옮기면 다음과 같다. 만약 우리가 공식적인 권한도 없이 통용되지 않는 것이라든가 거래관행이 아니라는 점을 들어 이러한 것들을 폐지하는 것은 위험한 일이라고 할 것이다. 그러나 아무런 어려움이나 혼란 없이 국민들이 악법에 반박하는 그리고 사회를 입법자들에 의해 행해진 놀라움으로부터 보호하는 그리고 입법자 자신으로부터 보호하는 보이지 않는 잠재력의 영향을 감출 수 있는지 의문이다.

평가하기 위하여 주석학과(Exégèse)의 '실행되는 법에 대한 예찬'(culte de la loi pratiqué)에 종지부를 찍은 사람이다. 즉, 주석학과의 그와 같은 입장은 당연히 그로 하여금 관습에 의해 배치되는 법의 효력에 대해 의문을 품게 하였다. 역으로, 또한 그 자신의 발상에 왜곡이 있음을 인정하면서, 그는 이 경우 정치적 안정보다는 법의 유지를 선호할 것이다.⁶⁴⁾ 다른 하나는 Hans Kelsen의 견해이다. 완전히 반대로, 그는 공표에 근거한 형식적 효과에 선택적 지위를 인정한다. 그리고 그는 더 나아가 심정적으로는 사실의 세계와 법의 세계의 구분에 천착하였다. 그러나 그의 입장이 현실에 부합하지 않는다는 것을 인정하면서, 그는 그의 저서 순수법학(Théorie pure)에서 효율성을 상실한 규범은 실효에 의해 그 효력을 상실한다는 것을 인정하게 된다.⁶⁵⁾ 그런데 법에 반하는 관행에 의해 혼란스러워 하는 것은 학자들만이 아니다. 즉, 법관들도 여전히 당혹스러워하며, 마르세이유 전차사건에서 채택된 것과 같은 엄격한 입장을 더 이상 견지하지는 않는다. 그러나 법관들이 반대되는 관행이 있다고 하여 법을 적용하지 않는다는 것을 공식적으로 인정할 수 없기 때문에, 관행에 반하는 법의 적용을 피하기 위한 방편으로서 신의칙이나 외관이론 또는 국제협약에의 불부합을 원용하게 될 것이다. 즉, 1977년법은 프랑스에서의 선거전 여론조사결과의 공표와 관련하여 이를 투표일을 기준으로 그 일주일 전에는 금지하였다. 그런데 2000년에 동법이 관행과는 간극이 있음이 드러났는데, 관행에서는 외국의 언론기관을 통하여 여론조사가 실현되고 있었고, 따라서 그 결과가 인터넷을 통하여 쉽게 알려지게 되었다. 따라서 파기원은 이 새로운 관행에 법이 적응하기 위하여 입법자가 개입할 때까지,⁶⁶⁾ 동법의 적용을 중단시키기 위하여 동법이 유럽인권협약(Convention européenne des droits de l'homme)에 반하는 것으로 평가하게 되었다.⁶⁷⁾ 국사원 또한 상황의 변화를 이유로 한 동법에 대한 이의를 접수한 후, 국사원이 상황의 변화를 이유로 법을 검열할 수는 없으며 법을 (상황의 변화에) 적응시키는 것은

64) 전게서, pp. 408 et s. : 모든 것을 고려하여, 그리고 선택을 하여야 하기 때문에, 그러나 오늘날의 요구조건을 고려할 때, 나는 원칙적으로 그리고 오늘날의 문명상황을 고려할 때, 성문법에 반하는 공식적인 모든 관습법을 거부하는 것이 타당하다고 생각한다. 나는 이러한 해결방안이 관습의 구속력을 부여하는 논리적이고 본질적인 근거를 찾지 못한다. 그러나 그 본질적인 면을 고려하면, 이러한 이유는 성문법을 정당화시키는 이유와 비교할 때 다소는 정당화될 수 있다. 그리고 순수한 논리는 무엇보다도 다양한 역사적이고 사회적인 고려에 속하는 문제를 결정할 수는 없을 것이다.

65) *Théorie pure du droit*, Dalloz, Collection Philosophie du droit, 2^e éd., 1962, p. 288 : 실제로, 법규범은 그것이 영속적으로 적용되지 않는다는 사실에 의해 그 효력을 상실할 수 있다. 즉, 우리는 이것을 낡음이라고 부른다. 비록 효율성이 유효성의 조건이기는 하지만, 판례를 통한 원칙에 따라 관습법의 창조적 역할을 부인할 수는 없을 것이다. 적어도 부정적인 기능 또는 파괴적 기능과 관련하여 '실효'(désuétude)라는 개념을 묘사할 수 있다.

66) 2002년 2월 19일 법 제2002-214호(loi n° 2002-214 du 19 février 2002).

67) Cass. crim., 4 septembre 2001, *Bull. crim.*, n° 170 ; *R.T.D.civ.*, 2002, 186, note R. Libchaber ; *J.C.P.*, 2001, II, 10 623, note A. Lepage et concl. D. Commaret.

오로지 입법자의 몫이라고 하였다.⁶⁸⁾ 사실, 이러한 이유는 위법성을 이유로 하는 것인데, 국사원은 이러한 이유를 명령에 해당하는 원칙의 유효성을 심사하는 경우에만 원용할 수 있다. 오로지 헌법위원회(Conseil constitutionnel)만이 법률에 해당하는 원칙의 유효성을 심판할 권한이 있다. 그런데 이 마지막의 사항과 관련하여, 실정법은 또한 관행의 파괴적 효력을 보장하였다. 사실 프랑스법에서는 비교적 최근에 들어서야 어떤 법률의 유효성을 사후적으로 헌법위원회의 통제를 받을 수 있도록 하고 있다. 그런데 이 사후적인 통제와 관련하여, 헌법위원회 위원들은 이미 어떤 법률의 검열근거를 발전된 관행에 근거하여 인정한 경우가 있다.⁶⁹⁾ 더 나아가 판례에서 발견되는 위헌성에 대하여 헌법위원회는 적합한 해석을 가리키면서 그러한 위헌성을 제거(또는 억제)할 수 있으며, 관행에서 위헌성이 인정된다고 하더라도 조문을 검열하는데 그치고 만다. 반대로, 법관은 관행에 대한 지도를 결정할 수 없다. 유일한 해법은 조문을 소멸시키는 것이며, 이를 통하여 관행도 소멸하게 될 것이다.

나. 다른 규범의 이의에 대한 관행의 저항

관행과 다른 법원의 충돌현상은 관행이 법을 거부하는 것에서 오는 것과 동일한 방향으로 일어나는 것은 아니다. 이러한 충돌은 다른 방향, 즉 법이 관행에 반하는 것에서 오는 것과 같은 방향으로 존재하기도 한다. 그런데 이러한 대립을 법의 관행에 대한 우위로 해석할 수 있을까? 아무튼 그에 대한 답변은 긍정적이다. 법관이나 (부정경쟁)위원회가 판단한 위법한 관행은 제재를 받게 된다. 그러나 그렇다고 하여 그러한 관행이 사라지는 것일까? 그런데 그러한 관행은 어쨌건 존속하는 경우가 있다. 즉, 수많은 상사관행은 국내의 통제를 피하여, 적법성요건이 보다 완화된 국제중재로 넘어가는 경우가 있다. 또 다른 관행은, 정기적으로 제재를 받음에도 불구하고, 그대로 유지되는 경우가 있는데, 그

68) C.E., 2 juin 1999, Meyet, *R.F.D.A.*, 1999, 873 ; *Petites Affiches*, 11 octobre 1999, p. 10, note E. Desfougères.

69) Cons. 16, 형사소송의 소위 리얼타임(en temps réel) 처리관행은 일반화되었다. 그리고 이러한 관행은 공소제기에 대한 검사의 결정이 경찰에 의한 감치를 끝내기 이전에 작성된 사법경찰리의 보고서에 근거하도록 이끌게 하고 있다. 그리고 비록 이러한 새로운 방법에 의한 공소제기는 올바른 사법행정의 목적에 부합하게 보다 빠르고 보다 다양한 형사적 답변을 가능하게 하였으나, 복잡하고 특히 중대한 행위에 관한 절차에 있어서는 여전히 어떤 사람이 감치기간이 끝나기 전에 수집된 증거방법들, 특히 이 기간 동안의 자백과 같은 증거들만에 근거하여 판단을 받게 되는 경우가 자주 있다. 즉, 감치(garde à vue)는 피의자를 재판하기 위한 절차에 있어서의 중요한 자료수집단계로 되는 경우가 자주 있다는 것이다.; 또한, cons. 29, 형사소송법 제62조, 제63조, 제63-1조, 제63-4조 제1항 내지 제6항 및 제77조는, 앞에서 이미 언급한 변화를 고려할 때, 감치로부터 행해진 활용에 부합하는 담보를 제공하지 않는다., *Décision* 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, *R.T.D.civ.*, 2010.5.13, P. Puig.

이유는 전문직업인에게 있어서 그와 같이 (제재 받을 관행을) 유지하는 것이 그 위법성을 이유로 일시적으로 제재금을 납부하는 것보다 더 수익성이 있을 수 있기 때문이다. 그리고 그러한 예로는 초과예약접수의 관행을 들 수 있다.⁷⁰⁾

그러나 이러한 사정에도 불구하고, 일정한 관행은 그에 대한 제재로 인하여 사라지게 될 것이다. 그런데 관행의 효력은 여기서 또 한 번 더 확고하게 인식된다. 사실 관행의 특징은 실행되었다는 것이며 또한 추측건대 그것도 지속적이고 보편적으로 실행되었다는 것이다. 즉, 법관이 그와 같은 관행 중 어느 하나의 적용이 위법하다고 판단할 때, 이는 그동안 정상적인 것으로 여겨진 동일한 관행에 따라 이미 행해진 수백 아니 수천의 행위가 불안정하게 되었다는 것을 의미한다. 그와 같은 일련의 파괴는 중대한 혼란을 초래한다. 이와 관련하여서는 소위 ‘상각명부’(tableau d’amortissement) 사건을 예로 들 수 있을 것이다. 파괴원은 완성된 상각명부를 제시하지 않고 체결된 부동산자금융자를 ‘이자 의 실효’(déchéance des intérêts)로써 제재함으로써 완화된 상각명부를 토대로 체결된 수많은 소비대차를 위태롭게 하였는데, 이러한 완화된 상각명부는 관련 부처의 답변에서도 유효한 것으로 간주한 관행이었다. 그런데 이러한 관행은 단 한 번도 관습으로 인정되었다거나 그와 같이 주장된 사실도 없다. 그리고 파괴적 효력에 있어서, 양자의 구별은 유용성을 상실한다. 이러한 사례에서 그리고 또 다른 유사한 사례로부터 얻을 수 있는 답변의 하나는 법률시스템의 지나친 혼란은 피해야 한다는 것이며, 따라서 위법한 것으로 인정된 관행을 따른 계약을 소급적으로 유효한 것으로 하는 법률의 채택하는 것 또한 피해야 한다는 것이다.⁷¹⁾ 또한 그와 같은 위법한 관행의 소급적 유효화는 유럽인권법원에 의한 프랑스의 제재로 이어졌는데, 국가경제를 뒤흔들만한 은행에 관한 분쟁의 경제적 논거가 충분히 긴급한 것으로 고려될 수 있을 만큼 충분히 뒷받침되고 있지 않다는 이유에서였다.⁷²⁾

그런데 이러한 소급적인 유효화의 시도는 관행이, 사실관계에서 일정한 영속성(permanence)을 가지고 정착되었다는 사실만으로, 법체계(ordre légal)에 의하여 고려되도록 강요하기에 이른다는 것을 반증한다. 즉, 아무리 관행의 규범적 효력을 부인하고자 하여도 소용이 없는데, 이는 관행이 갑작스럽게 사라지는 순간에 다음과 같은 사항이 반드시 드러날 것이기 때문이다. 즉, 계약은 사라지지 않으며, 단순한 사실도 아니며, 부대적인 현상도 아니다. 오히려 규범의 효력이 정지된다는 것인데, 그 규범은 그 형성과정에 있

70) Ph. Stoffel-Munck, précité, p. 36, sp. p. 42.

71) 1843년 6월 24일 법(Loi 24 juin 1843).

72) 14 fév. 2006, *Le Carpentier c. France*, L.P.A., 2006, n° 88, 12, note E. Garaud ; J.C.P., 2006, II, 10 171, note M. Thioye ; J.C.P., E 2006, 2062, note J. Raynaud ; R.D.C., 2006, 289, obs. Th. Revet et 879, obs. A. Debet.

어서 예견가능성과 정상적인 상태를 믿게 하였으며 또한 그러한 규범의 소멸은 관행에서 정착된 원칙을 변경하는 것이 매우 어렵다는 것을 알게 할 것이다. 관행도 마찬가지이다. 관행은 사실에 근거하기 때문에 잘 보이지 않으며 확인하기도 어렵다. 관행은 사실에 근거하기 때문에 위력적이고 통제하기가 힘들다.

〈참고문헌〉

- P. Amselek, "Brèves réflexions sur la notion de 'sources du droit'", *APD*, Tome 27, 1982.
- J. Carbonnier, "La genèse de l'obligation dans l'apparition de la coutume", in *Flexible Droit*, L.G.D.J., 9ème éd., 1998.
- F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, *Contrats civils et commerciaux*, Précis Dalloz, 5e éd., 2001.
- G. Cornu, *Droit civil, Introduction, les personnes, les biens*, 10e éd., Montchrestien, 2001.
- A. Couret et alii., *Droit financier*, Précis Dalloz, 1e éd., 2008.
- J. Cruet, *La vie du droit ou l'impuissance des lois*, Flammarion, 1908.
- J. DEPREZ, "Pratique juridique et pratique sociale dans la genèse et le fonctionnement de la norme juridique", *R.R.J.*, 1997-3, pp. 799 et s.
- P. Deumier, *Le droit spontané*, Economica, 2002.
- P. Deumier, "La force normative optionnelle", in *La force normative. Naissance d'un concept*, C. Thibierge (dir.), L.G.D.J., 2009.
- P. Deumier, *Introduction générale au droit*, Manuel, LGDJ, 2011.
- M. Favero, "La standardisation contractuelle, enjeu de pouvoir entre les parties et de compétition entre systèmes juridiques", *R.T.D.com.*, 2003. 429.
- Ph. Fouchard, *L'Etat face aux usages du commerce international*, TCFDIP, 1973.
- F. Génay, *Méthodes d'interprétation et sources du droit privé positif*, L.G.D.J., 2e éd., 1954.

- J. Gilissen, (dir.), *La rédaction des coutumes dans le passé et dans le présent*, Université libre de Bruxelles, 1962.
- B. Goldman, "Frontières du droit et 'lex mercatoria'", *A.P.D.*, Tome 9, 1964, pp. 177 et s.
- Ph. Jestaz, "Source délicieuse...", *RTD civ.*, 1993. 73.
- J.-M. Jacquet, Philippe Delebecque et Sabine Corneloup, *Droit du commerce international*, Précis Dalloz, 2e éd., 2010.
- A. Kassis, *Théorie générale des usages du commerce*, L.G.D.J., 1984.
- H. Kenfack et M. Pédamon, *Droit commercial*, Précis Dalloz, 3e éd., 2011.
- P. Malinverni, *Les conditions générales de vente et les contrats-types des chambres syndicales*, L.G.D.J., *Bibl. de droit privé*, Tome 154, 1978.
- N. Molfessis, *Les Petites affiches*, N° spécial 27 novembre 2003, n° 237.
- N. Molfessis, "Introduction", in *Les pratiques juridiques, source du droit des affaires*, L.P.A., 27 novembre 2003.
- C. Morel, "Le droit coutumier social dans l'entreprise", *Dr. soc.*, 1979, pp. 279 et s.
- J.-M. Mousseron, "LEX MERCATORIA Bonne mauvaise idée ou mauvaise bonne idée?", in *Mélanges L. Boyer*, Presses de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse, 1996.
- F. Osman, *Les principes généraux de la 'lex mercatoria'*, L.G.D.J., 1992.
- F. Ost et M. van de Kerchove, *De la pyramide au réseau?*, FUSL, 2002.
- F. Ravaisson, *De l'habitude*, Ed. FélixAlcan, 1933.
- B. Ricodeau, *La distinction des usages et des pratiques en droit économique français*, thèse, Orléans, 1983.
- Tanaka Kotaro, "Fonctions de la coutume en droit commercial", in *Mélanges F. Gény*, Tome 3, pp. 243 et s.
- F. Terré, *Introduction générale au droit*, Précis Dalloz, 9e éd., 2012.
- C. Thibierge, "Sources du droit, sources de droit : une cartographie", in *Mélanges Ph. Jestaz*, Dalloz, 2006.

LA PRATIQUE COMME SOURCE DU DROIT

Pascale Deumier*

<Résumé>

La pratique comme les sources du droit sont susceptibles de définitions très variées et, au plus large, leur étude pourrait recouvrir l'intégralité de la question de l'application du droit. Aussi, pour approfondir l'étude, il est au préalable indispensable de limiter le sujet en précisant dans quel sens il sera compris. Dans la présente étude, la pratique retenue sera « ce qui se fait » et les sources du droit seront les sources formelles, à l'exclusion des sources matérielles. Ainsi définies, il reste à essayer de comprendre comment des faits, informels, spontanés, difficiles à identifier, pourraient prétendre devenir des sources du droit, puisque ces dernières impliquent généralement des conditions prédéterminées aptes à produire des normes identifiables. La recherche du processus de formation de la pratique pourra aider à mieux comprendre ses effets. La formation de la pratique, reconstruite sous forme d'hypothèse, pourrait se faire par la répétition d'un même comportement, notamment contractuel, d'abord dans une relation interpersonnelle (relations d'affaires, usage d'entreprise) puis en s'étendant en généralité à tout un secteur. Elle deviendra alors un modèle de comportement détaché de son auteur, qui pourra s'appliquer dans le silence des parties à condition d'être devenu un usage. Ainsi reconstruit, le processus de formation ne permet toutefois pas d'identifier clairement les pratiques, notamment en distinguant les pratiques des usages et les pratiques des propositions professionnelles. Cette difficulté à identifier clairement la pratique ne va pourtant pas l'empêcher de se manifester comme une source du droit. Sa force créatrice pourra puiser aux fondements du contrat, de la loi ou de la coutume. Mais c'est essentiellement par sa force destructrice que la pratique révélera sa puissance : en effet, parce qu'elle est ce qui se fait normalement, la pratique aura été souvent suivie à grande échelle, et sa condamnation fait courir le risque de perturbations importantes pour le système juridique.

Mots-clés : source du droit, sources matérielles, sources formelles, pratique, usage, effet normatif, norme supplétive, désuétude.

* Professeur à l'Université de Lyon (Jean Moulin - Lyon 3)